

1000381-25.2022.8.26.0097

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: CLAUDIA DE ABREU MONTEIRO DE CASTRO

Comarca: Buritama

Foro: Foro de Buritama

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... tais valores, configuraria a cobrança sobre o tráfico jurídico, baseado em simples contrato, o que é vedado.

As tarifas questionadas TUSD e TUST, bem como os encargos setoriais, remuneram atividades relacionadas à prestação do serviço de fornecimento pelas redes básica e especial e manutenção do próprio sistema.

São, pois, atrelados aos meios utilizados para a prestação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buritama

Foro de Buritama

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Frei Marcelo Manília, 739, Buritama - SP - cep 15290-000

1000381-25.2022.8.26.0097 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1000381-25.2022.8.26.0097

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Deolindo Gardioli

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA DE ABREU MONTEIRO DE CASTRO

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Não é caso de deslocamento da demanda para a competência comum, eis que a controvérsia é eminentemente de direito, e o baixo valor da vantagem econômica pretendida atrai a competência do juizado. Lado outro, a competência absoluta deste juízo, quando não superado o valor de alçada, dá conta da correção do juízo em que ajuizada a demanda.

A preliminar de ilegitimidade passiva da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não comporta acolhimento porquanto o sujeito passivo da obrigação tributária é o consumidor final da energia elétrica, ou seja, a parte autora, que assumiu a condição de contribuinte de fato e de direito. Sendo consumidora final da energia elétrica, custeia o ICMS cujo pagamento considera indevido e tem legitimidade para pleitear a cessação das cobranças e a repetição do indébito tributário.

Noutra seara, não é mais cabível a suspensão do processo por força do IRDR nº 2246948-26.2016.8.26.0000, porque a suspensão dos processos acerca da matéria afetada se deu em 2017, e o CPC determina que, superado o prazo de julgamento do IRDR, de um ano, cessa a suspensão dos processos, em atenção aos princípios

constitucionais da duração razoável do processo, da economia e celeridade processual (CF, art. 5º, inciso LXXVIII; e CPC, art. 4º e 6º)

No mérito, a demanda é procedente.

Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito, para o fim de afastar da base de cálculo do ICMS a incidência das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD).

Como cedição, o ICMS caracteriza-se como tributo incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias. O fato gerador é a saída do estabelecimento do contribuinte, sendo devido o imposto somente com a entrega ao seu destinatário, quando ocorre a efetiva transferência da posse ou propriedade. O efetivo consumo, pelo destinatário final, é imprescindível para a caracterização do fato gerador do tributo.

Note-se que o ICMS incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, compreendendo negócio jurídico mercantil. O artigo 1º da Lei Estadual nº 6.374/89 estabelece que:

Artigo 1º - O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incide sobre: (Redação dada ao artigo pela Lei 10.619/00, de 19-07-2000; DOE 20-07-2000) I- operação relativa à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em qualquer estabelecimento;

(..)

O termo "circulação" deve ser entendido, conforme lição de Leandro Paulsen, como "a passagem das mercadorias de uma pessoa para outra, sob um título jurídico, sendo irrelevante a mera circulação física ou econômica" (PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de; Impostos: Federais, Estaduais e Municipais, 9ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 253).

Em outros termos, circulação é a mudança da titularidade jurídica do bem, e não a mera movimentação física.

Dessa forma, o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro não configura o fato gerador do ICMS. Nesse sentido, a súmula 166 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Igualmente não configura fato gerador do ICMS os atos de preparação e produção da mercadoria. Isto porque o conceito de mercadoria corresponde à ideia do bem corpóreo (ampliado constitucionalmente para abranger a energia elétrica, malgrado se trate de bem incorpóreo), resultado da atividade "profissional do produtor, industrial e comerciante, tendo por objeto a sua distribuição para o consumo (...) distinguindo-se das coisas que tenham qualificação diversa, como é o caso do ativo permanente".

Logo, conclui-se que apenas a circulação da mercadoria, como resultado da atividade profissional desenvolvida, é que configura fato gerador do ICMS. O fato gerador, portanto, é a saída do estabelecimento do contribuinte com a entrega ao seu destinatário, momento em que ocorre a efetiva transferência da posse ou propriedade.

Veja-se que o consumo efetivo, pelo destinatário final, é imprescindível para a caracterização do fato gerador do tributo.

Portanto, ainda que a preparação, produção e distribuição sejam etapas para o fornecimento de energia elétrica, certo é que são atividades-meio, e, assim, não podem integrar a base de cálculo para o tributo, na ausência de previsão legal. A incidência sobre tais valores, configuraria a cobrança sobre o tráfico jurídico, baseado em simples contrato, o que é vedado.

As tarifas questionadas TUSD e TUST, bem como os encargos setoriais, remuneram atividades relacionadas à prestação do serviço de fornecimento pelas redes básica e especial e manutenção do próprio sistema.

São, pois, atrelados aos meios utilizados para a prestação do serviço, daí o não cabimento de sua consideração na base de cálculo do tributo.

Nesse sentido:

"ICMS. Energia elétrica. Tarifas de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) - Inocorrência de hipótese de incidência que admita utilização dessas tarifas na base de cálculo do imposto. Inexistência de "circulação" de mercadoria. Precedentes. Legitimidade ativa para a repetição. Impossibilidade de condenação em pagamento de honorários contratados com advogado. Recurso fazendário improvido, e recurso da empresa autora parcialmente provido." (Apelação nº 1009577- 98.2015.8.26.0053, rel. Des. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, j. 14/12/2015).

"APELAÇÃO. Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito. ICMS. Transmissão de energia elétrica Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia Elétrica" TUSD e TUST e encargos de conexão Sentença que julgou procedente a demanda Alegação de ilegitimidade ativa e custo operacional do sistema que deve ser suportado por quem o utiliza Pretensão de improcedência da ação - Inadmissibilidade Transmissão e distribuição de energia elétrica que não compõem o fato gerador do ICMS Legitimidade da empresa autora pacificada em recentes decisões do E. STJ Sentença de primeiro grau que será mantida- Recurso desprovido." (Apelação nº 1019266-69.2015.8.26.0053, rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, j.11/04/2016).

Aplica-se, ainda, ao caso em análise, a Súmula nº 391 do E. STJ: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada".

Na situação dos autos, há circulação econômica com transferência da propriedade da energia elétrica apenas no momento em que esta é efetivamente consumida pelo destinatário, o que não ocorre na fase de transmissão e distribuição, que são meras etapas necessárias à prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

Portanto, pelo todo exposto acima, forçoso concluir pela ilegalidade da cobrança do ICMS sobre os valores referentes à TUST e TUSD e demais encargos setoriais, porquanto estão fora do âmbito do tributo.

Sobre o valor a restituir, mister que se adicione correção monetária desde o desembolso de acordo com a Tabela Prática do TJ/SP até o trânsito em julgado e, a partir de então, deverá ser aplicada a taxa SELIC (que abrange os juros de mora e correção monetária), conforme decidido pelo C.STJ no Recurso Especial nº 1.111.189/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 19) e consoante art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ ("Os juros moratórios, na repetição de indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença"), pois, tratando-se de repetição de indébito tributário não tem incidência a Lei 11.960/09.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Deolindo Gardioli em face do FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para declarar definitivamente a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes que obrigue o autor a proceder ao pagamento do ICMS incidente sobre os valores devidos a título de TUST e TUSD, na instalação elétrica de nº 7197519, definindo-se a base de cálculo do referido tributo como sendo, unicamente, o montante relativo à energia elétrica efetivamente consumida, devendo a ré se abster de praticar medidas coercitivas relativas à referida cobrança. Condeno a ré à repetição de indébito pago, devidamente apurado em liquidação de sentença, referente à inclusão na base de cálculo do ICMS dos valores a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) de energia elétrica das mencionadas instalações, respeitada a prescrição quinquenal e desde que comprovados os respectivos recolhimentos, acrescidos de correção monetária e juros de mora como acima exposto. Desta feita, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar a imediata exclusão da tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica da base de cálculo do ICMS da conta de energia do imóvel situado na Avenida Frei Marcelo Manília, 534, Centro - CEP 15290-000, Buritama-SP (Unidade Consumidora nº ). OFICIE-SE à ELEKTRO, comunicando-se.

Sem custas e honorários.

P.R.I.

Buritama, 29 de junho de 2022.